

1500494-45.2019.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... foi atender uma ocorrência envolvendo o tráfico de drogas. Informa que ocorreu por volta das 16 horas na praça João Batista, a partir de reclamação de professores sobre o tráfico no local. Em campanha verificou quando a ré junto com terceiros se revezavam na entrega de drogas para usuários que chegavam no local. Na abordagem teve uma ocorrência, sendo que a ré foi abordada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500494-45.2019.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-45.2019.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 830/19/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2102232 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2102232/2019 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 4601806 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA LIVIA ALVES ISAC

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Ana Livia Alves Isac, como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 16h30, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, Vale do Redentor, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, nas dependências de recinto onde se realizavam diversões de qualquer natureza, 20 (vinte) porções de crack, pesando 3,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 273/275 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/05 e Boletim de Ocorrência nº 830/2019.

Foi expedido alvará de soltura sem medida cautelar (págs. 42/43).

O réu foi devidamente citado (pág. 313) apresentou defesa preliminar (págs. 296/301), aduzindo, em síntese, que os elementos probatórios, nesta fase, a respeito do tráfico ilícito de drogas, são demasiadamente precários, insuficientes e imprecisos para sustentar o recebimento da denúncia. Apresentou rol de testemunhas.

A denúncia foi recebida ao 15 de março de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 314/316).

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados. Na fase do art. 402 do CPP, aplicável por analogia, nada foi requerido.

Em debates, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição da acusada, e pedidos subsidiários, conforme mídia audiovisual.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 09/10), auto de constatação preliminar (págs. 15), e pelo laudo pericial de páginas 71/72.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

João Carlos Mancuso informou que foi atender uma ocorrência envolvendo o tráfico de drogas. Informa que ocorreu por volta das 16 horas na praça João Batista, a partir de reclamação de professores sobre o tráfico no local. Em campanha verificou quando a ré junto com terceiros se revezavam na entrega de drogas para usuários que chegavam no local. Na abordagem teve uma ocorrência, sendo que a ré foi abordada pelos policiais. No momento indicou que era seu namorado o responsável pelo tráfico.

Existe imagens feitas pela policia militar.

Ataildo Bispo Gouvea informa que fez campana com um colega e ao realizar abordagem encontraram uma mesinha e drogas que foram apreendidas.

A testemunha de Defesa Juliana Pereira da Silva Fernandes informa que recebeu telefonema na residência informando que a ré tinha sido presa, já que a ré pegava seu filho na creche. Teceu considerações sobre a vida pregressa da ré e se possui filhos.

A ré em juízo negou o fato, desconhecendo o traficância. Estava esperando apenas o momento para pegar seu filho na creche e da moça da qual cuidava. Informa que conhece os adolescentes de vistas. Informa que a creche é do outro lado da calçada. Informa que matriculou o filho na creche e que tem documentos.

2 -) DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais

testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que em se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

No caso sub apretiationis, o réu tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, nas dependências de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, 20 (vinte) porções de crack.

Diante do panorama probatório, conclui-se que a conduta praticada pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal esculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Nova Lei de Drogas), consideradas as circunstâncias que permearam a apreensão dos entorpecentes.

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

A negativa de autoria da ré nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Por serem isentas, preponderam as provas acusatórias contra o réu e demais indícios de seu envolvimento na atividade criminosa objeto da denúncia.

Destarte, não há resquício de dúvida de que todos estes fatores conjugados evidenciam a absoluta preponderância dos elementos angariados pela acusação que

logrou fazer com que o fiel da balança pendesse no sentido da pretensão punitiva.

Não se pode desconsiderar os indícios como meio de prova e seu valor. O Art. 239 do CPP prevê : Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Nos dizeres de Malatesta "Os indícios não merecem, certamente, uma apoteose, mas também não merecem a excomunhão maior."

A conclusão obtida neste Juízo é a de que neste processo obteve-se indícios graves, precisos e concordantes, hábeis a respaldar o raciocínio indutivo-dedutivo acerca da culpabilidade do réu, pois teria sido avistado em três situações típicas de entrega de droga, com aproximação de veículos que logo iam embora, em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem qualquer explicação plausível após ter sido apreendido na menoridade pela prática de atividade idêntica.

As partículas do fato principal pinçadas nesta decisão revelam condições firmes e seguras que permitem visualizar o envolvimento de Ana Livia Alves Isac na prática de tráfico de entorpecentes, restando inviabilizada a desclassificação almejada pela defesa ou absolvição por falta de provas.

Ademais, a versão da ré que estava esperando seu filho na creche não encontra respaldo, já que toda atuação da polícia deu-se uma hora antes da saída do filho creche. Ora, não se mostra lógica a presença da acusa numa praça 1 horas antes da liberação do seu filho, justamente num local conhecido pela prática de tráfico no local.

Além disso, todo desenrolar foi presenciado pelo policial João Carlos Mancuso, além disso, a ré possivelmente utiliza-se do fato de ter um filho matriculado na creche para justificar sua permanência no local.

Por fim, não se mostra necessário apreender usuários para justificar a condenação quanto ao crime de tráfico.

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de pgs. 47/50 para CONDENAR ANA LIVIA ALVES ISAC pela prática do crime capitulado no artigo, caput, c.c o artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário - súmula 444 do E. STJ.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

No que se refere à quantidade de drogas, critério definido no art. 42 da Lei de Drogas, observa-se que a quantidade de drogas que estava em posse pela ré não passava de poucos gramas de crack, de modo que nada altera a dosimetria

A ré é primária, pois não há qualquer condenação anotada nas pgs. 285/286.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Rejeito a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006.

A denúncia situa os fatos na Praça João Batista Ribeiro de Lima. A própria denúncia diz que se trata de conhecido ponto de tráfico de drogas, portanto não é local para qualquer diversão ou espetáculo público. Fato público e notório nesta cidade.

Não se pode emprestar qualquer amplitude ao termo "praça" para confundi-lo com "recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza", pois com apoio léxico tem-se que "recinto é local cercado ou fechado"(Dicionário Aurélio, Ed. Positivo, 3.ed, 2004, vocábulo "recinto" p. 1709).

Ao contrário de "recinto", uma praça é um local geralmente amplo e aberto, bem de uso comum. Aumentar a pena neste caso seria proceder com clara analogia in malam partem.

Há praças de maiores ou menores dimensões espalhadas pelo centro e bairros da cidade. Apenas na parte central são vizinhas e quase contíguas as praças do Epidauro; a praça dos 3 Poderes e a praça Cândido Ribeiro, todas circundadas por escolas nas adjacências.

Assim, o fato de que o réu tenha sido avistado em uma "praça" não autoriza a exasperação de pena na forma pretendida pelo Ministério Público, uma vez que não se

trata de "recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza".

A cidade de São José do Rio Pardo é relativamente pequena. Tem cerca de 55.000 habitantes. Existem diversas praças, escolas, locais de atendimento público espalhados pela urbe, de modo que encampar a tese ministerial também ocasionaria que em praticamente todos os tráficos de entorpecentes nesta cidade ensejassem a incidência da majorante em verdadeira e inaceitável aplicação de responsabilidade penal objetiva, violando o finalismo penal. Estariam livres apenas, em tese, traficantes que se utilizassem da zona rural.

A ré faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois primária e a quantidade de entorpecentes era pequena. De outro lado, presente a causa de aumento prevista no ar.40, inciso VI da Lei de drogas pela circunstância de toda ação delitiva contar com a participação de adolescentes. Assim, prevalecendo a causa de diminuição, reduzo essa em 1/3 fixando-a em 3 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº.110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art.2º, §2º, da Lei nº.8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art.44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art.83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam a penas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art.33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Onde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a egrageral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, ate ordos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art.83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu iniciou o cumprimento da pena sobre o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STFº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Para melhor ilustrar:

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART.33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018).

TJSP-TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA PENA MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO- QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018).

TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton

Neves. j. 09.11.2018, Publ.09.11.2018).

O regime deve ser o ABERTO, diante dos precedentes supra, bem como levando em conta a primariedade da ré, a pena inferior a 4 anos e a detração.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC.101.291 SP, relatado pelo Ministro Eros Grauno Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras como entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 -SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juízo arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituirá pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Para este Juízo não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestarem serviços comunitários.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

Com efeito, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j.16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j.17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semiaberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Por fim, a ré não dispõe de senso de responsabilidade suficiente para qualquer medida alternativa. Verificou-se no curso do processo que descumpriu as condições da liberdade provisória.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, ficando suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPCC.C art. 3º do CPP, pois defiro-lhe à ré, patrocinada por advogado dativo, os benefícios da AJG.

Honorários na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão no regime aberto, facultando-se à ré apresentar-se em Juízo nos dias úteis das 13:00 às 16:30 para que sua audiência admonitória seja "encaixada" na pauta regular, prevenindo a intervenção da polícia para o cumprimento do mandado de prisão;

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

*

Sao Jose do Rio Pardo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA